

<제6장 인사처분.제3절 전적>

I. 의의

- 전적이란 근로자가 원래의 사용자(구 사용자)와의 근로계약 관계를 종료하고, 새로운 사용자(신 사용자)와 새로운 근로계약 관계를 설정하는 것을 의미한다. 이는 동일한 기업 내에서 직무나 근무지만 바뀌는 전직과 달리, 근로계약의 주체(사용자)가 변경되는 것이 핵심적인 특징이다. 전적은 일반적으로 기업 집단 내 계열사 간 인력 이동이나 사업 부문의 양도 등에 수반하여 이루어진다. 전적은 근로자에게 고용 주체의 변경 및 근로조건의 변화라는 중대한 영향을 미치므로, 법적 규율이 엄격하게 적용된다.

II. 전적명령의 유효요건

- 전적은 근로계약 관계의 주체인 사용자의 변경을 수반하는 법률행위이므로, 단순한 인사명령을 넘어 근로자의 동의가 필수적으로 요구되며, 통상 3자간의 계약의 형태를 취한다.

1. 전적계약

(1) 개념

- 전적은 구 사용자와의 근로계약의 합의해지와 신 사용자(전적 대상 회사)와의 근로계약 신규 체결이 결합된 복합적인 법률행위이다. 따라서 전적이 유효하게 성립하기 위해서는 구 사용자, 신 사용자, 근로자 등 최소 3자 간의 합의 또는 계약이 필요하다.

(2) 법적 성격

- 전적은 근로관계의 중단과 개시를 동시에 포함하므로, 계약의 자유 원칙에 따라 당사자들의 의사가 전적으로 존중된다. 전적계약에서는 퇴직금 지급, 근속기간 승계, 연차휴가 처리 등 구체적인 근로조건과 관련하여 당사자 간의 명확한 합의가 있어야 한다. 특히, 근로자에게 불리한 근로조건 변경은 그에 상응하는 합의를 요한다.

2. 근로자의 동의

(1) 원칙

- 전적은 근로자의 고용 주체를 바꾸는 행위로서, 근로자에게 신분상, 재산상, 생활상 중대한 영향을 미치기 때문에, 원칙적으로 근로자의 개별적이고 명시적인 동의가 있어야 유효하다. 근로자의 동의가 없는 전적명령은 무효이다.

(2) 포괄적 동의의 유효성

① 단체협약 또는 취업규칙의 규정

- 단체협약이나 취업규칙에 전적에 관한 포괄적 동의 조항이 규정되어 있는 경우, 근로자가 이에 대해 포괄적으로 동의하였다고 볼 수 있는지 여부가 문제된다.

② 판례의 태도

- 판례는 단체협약이나 취업규칙에 포괄적 동의 조항이 있더라도, 그러한 규정만으로 근로자의 개별적인 동의 없이 전적을 명할 수 있다고 단정할 수 없다고 본다.

③ 유효성 인정 요건

- 다만, 예외적으로 포괄적 동의 조항이 유효하기 위해서는 해당 조항이 근로자에게 불리하지 않고 그 적용에 합리성이 있는 경우에 한하며, 개별 전적 시에도 전적의 업무상 필요성 및 근로자 이익과의 비교 형량을 통해 정당성을 갖추어야 한다. 즉, 단체협약 등의 포괄적 동의는 전적의 정당성 판단 시 고려되는 하나의 요소일 뿐, 개별적 동의를 완전히 대체할 수는 없다고 본다.

III. 전적명령의 정당성

- 설령 근로자의 개별적 동의 또는 포괄적 동의를 얻었더라도, 사용자의 전적명령권은 무제한적으로 허용될 수 없으며, 재량권 일탈·남용 금지의 법리에 따라 객관적인 정당성이 인정되어야 유효하다.

1. 업무상 필요성

(1) 의의

- 전적을 명할 합리적이고 상당한 수준의 업무상 필요성이 있어야 한다. 이는 기업의 경영 합리화, 계열사 간 인력 운영 효율 증대, 특정 사업 부문의 양도 등 광범위한 사유를 포함할 수 있다.

(2) 판단 기준

- 업무상 필요성은 구체적인 전적 상황과 당시의 경영 환경 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단되어야 한다. 단순한 사적 이익이나 보복성 인사는 업무상 필요성을 인정받을 수 없다.

2. 근로조건의 불이익 정도

(1) 의의

- 전적으로 인해 근로자가 입는 생활상 또는 경제상의 불이익이 어느 정도인지 판단해야 한다. 전적은 고용 주체의 변경 자체로 불이익을 내포하고 있으므로, 특히 종전의 근로조건 유지에 대한 검토가 중요하다.

(2) 불이익의 판단 요소

- ① 임금, 퇴직금, 복리후생 등 경제적 근로조건의 불이익 여부. ② 근속기간 승계의 보장 여부 (승계가 이루어지지 않으면 퇴직금, 연차 등에서 불이익 발생). ③ 직무 내용 및 근무 장소의 변경으로 인한 근로자의 생활상 불편 정도. ④ 전적 대상 회사의 재정 상태 및 안정성 등 고용 불안정성 증가 여부

(3) 비교 형량

- 전적으로 인한 근로자의 불이익이 업무상 필요성과 비교하여 근로자가 통상적으로 감수해야 할 합리적인 범위를 벗어나서는 안 된다. 만약, 불이익이 과도하다면 정당성이 부정될 수 있다.

3. 근로자 본인과 합의 등 절차적 정당성

(1) 의의

- 전적명령 과정에서 근로자의 개별적인 동의뿐만 아니라, 신의칙상 요구되는 충분한 합의 절차를 거쳤는지 여부가 정당성 판단에 중요한 요소로 작용한다.

(2) 합의 내용

- 전적 대상 회사(신 사용자)의 근로조건, 임금 체계, 복리후생, 고용 보장 등에 대해 근로자에게 충분히 설명하고, 근로자의 의사를 존중하려는 노력을 기울였는지 여부를 본다. 특히, 중대한 불이익이 예상되는 경우에는 더욱 엄격한 합의 노력이 요구된다.

N. 부당전적의 효과

1. 전적명령의 무효

(1) 원칙

- 전적명령이 유효요건(개별적 동의)을 갖추지 못했거나, 정당성 기준을 충족하지 못하여 사용자의 재량권을 일탈·남용한 경우, 해당 전적명령은 무효이다.

(2) 법률관계

- 전적명령이 무효인 경우, 근로자는 원래의 사용자(구 사용자)와의 근로계약 관계가 종료되지 않고 유지되며, 신 사용자에게 근로를 제공할 의무가 없다. 근로자는 구 사용자에게 임금 지급 청구 등 종전의 권리를 행사할 수 있다.

2. 근로자의 구제

(1) 구제 절차의 특수성

- 부당전적은 근로기준법상 해고나 징계에 해당하지 않으므로, 근로기준법 제28조에 따라 노동위원회에 부당해고등 구제신청을 할 수 있는 직접적인 대상은 아니다.

(2) 사법적 구제

① 전적 무효 확인 소송

- 근로자는 법원에 전적명령의 무효 확인을 구하는 소송을 제기하여 구 사용자에게 복직을 요구할 수 있다.

② 해고 무효 확인 소송

- 근로자가 부당한 전적명령을 거부하였다는 이유로 구 사용자가 근로자를 해고한 경우, 근로자는 해당 해고의 무효 확인 소송을 제기할 수 있다. 이 경우 법원은 전적명령의 부당성을 판단하여 해고의 정당성 여부를 심리한다. 판례는 정당성을 잃은 전적명령에 대한 거부를 이유로 한 해고는 부당해고라고 본다.

③ 손해배상 청구

- 부당전적으로 인해 근로자가 손해를 입은 경우, 사용자를 상대로 민법상 채무불이행 또는 불법행위에 기한 손해배상을 청구할 수 있다.

V. 전적 후의 근로관계

1. 근로계약의 주체 변경

- 전적이 유효하게 이루어진 경우, 근로자는 구 사용자와의 근로관계를 종료하고, 신 사용자에게 고용되어 새로운 근로계약 관계를 맺는다. 근로조건은 원칙적으로 신 사용자와 새롭게 체결한 근로계약의 내용에 따른다.

2. 근속기간의 승계

(1) 문제점

- 전적은 근로계약의 단절을 전제로 하므로, 근로자의 근속기간이 전적 전후로 통산되는지 여부가 중요하게 다루어진다. 근속기간은 퇴직금, 연차휴가, 승진, 호봉 등의 산정 기초가 되기 때문이다.

(2) 판례의 태도 및 판단 기준

- 판례는 전적이 있는 경우 근속기간 통산 여부는 당사자 사이의 합의에 달려있다고 본다.

① 통산 합의가 없는 경우

- 원칙적으로 근속기간은 단절되며, 구 사용자는 근로자에게 퇴직금을 정산하여 지급해야 한다.

② 통산 합의가 있는 경우

- 전적 합의, 단체협약, 취업규칙 등에 근속기간을 통산하기로 하는 명시적인 약정 또는 묵시적인 합의가 있는 경우에만 근속기간이 승계된다.

(3) 실무상 유의사항

- 대규모 기업 집단 내의 전적에서는 대부분 근속기간 통산을 명시적으로 약정하며, 통산 합의가 있다면 신 사용자에게 최종 퇴직 시 전 기간에 대한 퇴직금 지급 의무가 발생한다. 다만, 구 사용자가 미리 정산하여 지급한 금액은 신 사용자의 의무에서 공제된다.

VI. 결론

- 전적은 사용자의 변경이라는 중대한 법률 효과를 수반하므로, 근로자의 개별적이고 명시적인 동의를 얻는 것이 그 유효성의 핵심 요건이다. 설령 동의를 얻었다 하더라도 업무상 필요성과 근로자의 불이익을 비교 형량하여 재량권 남용이 없는 정당성이 인정되어야 한다. 부당전적은 무효이며, 근로자는 사법적 구제 절차를 통해 구 사용자에게 복직을 요구하거나 손해배상을 청구할 수 있다. 전적 후의 근로관계에서는 근속기간의 승계 여부가 당사자 간의 합의에 따라 결정되는 중요한 쟁점임을 유념해야 한다.